

0024542-87.2014.8.26.0068

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/08/2022

... SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. NATUREZA DA DROGA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. DO ART. 33, § 4º, DA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barueri

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0024542-87.2014.8.26.0068 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0024542-87.2014.8.26.0068

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato

Réu:

Esdras Marcolino de Assis Junior

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

Esdras Marcolino de Assis Junior, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) por duas vezes no artigo 171, "caput", do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal, porque no dia 13 de março de 2014: a. às 17h26 na Rua Rua Topázio, 313, Jardim dos Camargos, nesta cidade e comarca de Barueri, obteve para si, vantagem ilícita, no valor de R\$ 800,00 em prejuízo de Miguel Vítor Rebelles de Oliveira, induzindo-a e mantendo-o(a) em erro mediante fraude consistente na apresentação de moeda falsa como forma de pagamento de produtos; e, b. nesta cidade e Comarca de Barueri, obteve para si ou para outrem vantagem indevida no valor de R\$ 1.300,00 em prejuízo da vítima Josué Araujo Rebelles, induzindo-a e mantendo-a em erro mediante fraude, consistente na apresentação de moeda falsa como forma de pagamento de produtos.

A denúncia foi recebida em 20 de março de 2019 somente quanto ao crime descrito no item "a" (fl. 154).

O(A) ré(u) foi citado(a) (fl. 180) e apresentou defesa preliminar (fls. 185/187).

Ela foi rejeitada e foram determinadas providências para realização da instrução

por videoconferência, depois designou-se audiência (fls. 191 e 217). Durante a instrução uma vítima prestou declarações, uma testemunha prestou depoimento e o(a) ré(u) foi interrogado(a).

As partes apresentaram alegações finais

É o relatório. Decido.

O(A) ré(u) foi processado porque em 13 de março de 2014, nesta cidade e Comarca de Barueri, obteve para si ou para outrem vantagem indevida no valor de R\$ 1.300,00 em prejuízo da vítima Josué Araujo Rebelles, induzindo-a e mantendo-a em erro mediante fraude, consistente na apresentação de moeda falsa como forma de pagamento de produtos.

De acordo com a denúncia, Miguel anunciou na internet a venda de um video-game, o réu o contatou e comprou o bem, realizou o pagamento pessoalmente, mas com notas de dinheiro falsas, coisa que a vítima só notou depois de efetuar a transação.

Posteriormente, Miguel, sobrinho da vítima, anunciou também a venda de um video-game X-box 360, sendo que, novamente, o réu o contatou e marcaram um encontro, mas desconfiando da fraude, Miguel chamou também o tio. Percebendo que se tratava do mesmo agente que anteriormente havia enganado Josué, acionaram a guarda civil.

A denúncia foi recebida apenas com relação ao crime que o réu teria praticado contra a vítima Miguel e rejeitada quanto ao crime que ele teria praticado contra a vítima Josué.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática desse crime contra a vítima Miguel. Ele disse que não conhece a vítima Josué, tio de Miguel. Conhece Miguel porque estava mesmo interessado em comprar o video-game dela para dar ao seu filho. Foi à casa dela e fazia o teste no aparelho quando os guardas civis chegaram e o prenderam. Tinha consigo R\$ 800,00. Não eram cédulas falsas.

Essa negativa, contudo, não merece prosperar. As peças informativas colhidas durante o inquérito policial, assim como as provas irrepetíveis e as produzidas em juízo demonstram que ele praticou, sim, o crime de que é acusado, ou seja, o estelionato.

O auto de exibição e apreensão mostra as cédulas apreendidas (fls. 7/8) e o laudo pericial atestou a falsidade delas (fls. 38/41). Nem se diga que essas cédulas se destinariam apenas à compra do video-game de Miguel, fato que não é apreciado neste feito por conta da rejeição da denúncia. É que a soma dos valores é superior ao valor do negócio que o réu firmaria com Miguel. Crível, portanto, que as cédulas falsas que o réu entregou à vítima Josué tenham sido guardadas por ela até que o estelionatário que a enganou fosse identificado, como, de fato, aconteceu.

Em solo policial a vítima Josué declarou que anunciara um video-game para vender na internet. O réu fez uma proposta e marcaram encontro para realizarem a entrega do bem e o pagamento respectivo, em dinheiro. Tudo correu como combinado, mas depois o depoente descobriu que o dinheiro recebido do réu era falso. Guardou os R\$ 1.300,00 em cédulas falsas. Não registrou ocorrência na época, mas depois o mesmo ocorreu ao sobrinho do depoente. Desconfiado, foi até a casa do sobrinho na data do encontro com o réu e o reconheceu, então acionaram a guarda civil.

A vítima morreu, por isso não prestou depoimento em juízo. A despeito disso, como permite o artigo 155 do Código de Processo Penal, essa peça informativa pode ser levada em consideração para a condenação do réu, pois corroborada por provas produzidas em juízo.

Miguel declarou em juízo que anunciou a venda de um video-game usado na internet. Um comprador o contatou e marcaram encontro na casa do depoente para efetivar a transação. A pessoa dizia que queria comprar o aparelho para o filho da patrona. Ficou desconfiado do comprador porque o seu tio, vítima Josué, tinha sofrido um "golpe" de um comprador de video-game que tinha dito a mesma coisa. Marcou encontro com o comprador e avisou o seu tio, vítima Josué. O réu compareceu e recebeu dele R\$ 800,00 dele, mas notou algo estranho nas notas. Seu tio Josué reconheceu o réu. Acionaram então a guarda civil e foram todos para a delegacia. Por conta disso é que o réu não levou consigo o seu video-game. Sabe que o seu tio Josué ficou com o prejuízo, pois entregou o video-game, mas não recebeu o pagamento. Também sabe que ele guardou as cédulas falsas.

Por seu turno, a testemunha Denis afirmou em juízo que é guarda civil municipal e

na data do fato foi acionado ao local porque um homem que havia tentado praticar estelionato estava detido pelas vítimas. No local apurou que o réu contatara as vítimas após elas anunciarem a venda de um equipamento eletrônico na internet. Nos dois casos ele fizera uma proposta, depois marcou encontro com as vítimas, mas realizou o pagamento com notas de dinheiro falsificadas. Os fatos ocorreram a intervalo de meses e a primeira vítima, tio da segunda, não havia registrado ocorrência, mas reconheceu o réu como sendo o mesmo homem que a enganara. As vítimas entregaram o dinheiro falso que haviam recebido do réu e mais notas do mesmo tipo foram apreendidas no carro dele.

Essas provas denotam que o réu ludibriou a vítima Josué com cédulas falsas, obtendo, como contrapartida do pagamento feito com elas, o video-game dela. Isso caracteriza o crime de estelionato consumado.

Passo à dosagem da pena.

O crime do artigo 171, "caput", do Código Penal tem pena-base de 1 a 4 anos de reclusão, e multa.

Na primeira fase de aplicação da pena, verifico que o réu ostenta maus antecedentes: ele foi condenado nos autos 0003370-18.2004, 1ª Vara Criminal do Foro Regional de Pinheiros, sentença transitada em julgado em 06/10/2005, pena extinta em 05/06/2006 (fl. 198).

Além disso, o réu foi condenado no curso deste processo, sentença passada em julgado em 17/09/2020, por ato praticado antes do que está agora sendo julgado, em 20/03/2013 (autos 00149156220134036181 - fls. 199/200), apontamento que deve ser valorado nesta etapa da dosimetria da pena, como mau antecedente.

A lei não define o que são maus antecedentes. Nada impede, portanto, que sejam definidos os maus antecedentes como os atos criminosos que constam da folha de antecedentes do réu, que tenham sido praticados em data anterior à sentença. O princípio do "in dubio pro reo" é pertinente à possibilidade ou impossibilidade de apenar o réu, não à fixação da pena adequada em caso de condenação.

Nem se diga que não pode ser considerada uma circunstância judicial posterior à data da prática criminosa, porque o próprio artigo 59 do Código Penal permite isso ao mencionar as consequências do crime. Também não deve ser aceita a tese de que o parâmetro para a aplicação das circunstâncias judiciais do referido diploma legal é sempre a data do crime, e daí os antecedentes somente poderiam ser anteriores ao delito. Isto porque não há base legal para tal entendimento, e, ademais, nada impediria que fosse considerada a conduta social do réu após a ocorrência do crime, ou que a sua personalidade fosse aferida por fatos posteriores a este. Assim, nada impede também que os antecedentes criminais sejam posteriores à data do delito, desde que anteriores à data da sentença.

Na espécie, interpretação contrária levaria à impossibilidade de consideração do crime que levou o réu a ser condenado definitivamente no curso deste feito, em cuja sentença, por sinal, também não foi considerado o presente delito, justamente pelo fato de o processo ainda estar em curso. Isto significa que haveria a prática de mais de um crime sem aumento de pena em qualquer das sentenças, o que é injustificável, pois se deixa de punir o agente criminoso de maneira proporcional à ofensa, que, no caso, deveria considerar a reiteração. Deve prevalecer, destarte, essa interpretação teleológica.

Tanto é assim que, em acórdão relatado pelo E. Desembargador Fernando Torres Garcia, em sede de Apelação Criminal interposta contra sentença por mim proferida, sob n. 0001600-35.2009.8.26.0586, tratou da seguinte forma a impugnação apresentada pela defesa acerca do tema: "Não se trata, ao contrário do que sugerido pela combativa defesa, de mero processo em andamento, pois o fato lá noticiado foi praticado em data anterior ao crime destes autos e com trânsito em julgado para as partes em data posterior, o que corretamente configurou os maus antecedentes".

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica do julgado abaixo:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. MAUS

ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. NATUREZA DA DROGA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO). CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO DELITO. CRITÉRIO IDÔNEO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. FALTA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

4. A valoração da condenação anterior com trânsito em julgado posterior pode caracterizar circunstância judicial desfavorável, nos termos da jurisprudência reiterada desta Corte, segundo a qual "restam configurados os maus antecedentes sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por delito anterior, independentemente do momento do seu trânsito em julgado, se anterior ou posterior ao crime em análise" (REsp 1465666/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 02/10/2014, DJe 09/10/2014).

(...)"

(STJ - 5ª T., HC 359759/RS, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22/09/2016)

Em razão dos maus antecedentes, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 2 anos de reclusão.

Na segunda fase de aplicação da pena não há agravantes nem atenuantes. As demais condenações do réu ou referem-se a fatos posteriores ao sob exame, ou então não transitaram em julgado, por isso não caracterizam reincidência.

Por fim, não há causas de aumento ou de diminuição de pena na terceira fase.

A pena privativa de liberdade a ser cumprida pelo réu, portanto, fica consolidada em 2 anos de reclusão.

Tendo em vista a pena aplicada e a primariedade do réu, ele tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Deverá prestar serviços à comunidade pelo mesmo período acima e pagar 1 salário mínimo a título de prestação pecuniária.

A pena de multa segue os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, de tal modo que fica consolidada em 20 dias-multa. Considerando que o valor dessa pena deve seguir a condição econômico-financeira do réu e, no caso em tela, o que foi dito acima acerca da pena pecuniária serve para resolver este ponto também, fixo o dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o réu ESDRAS MARCOLINO DE ASSIS JUNIOR como incurso(a) no artigo 171, "caput", do Código Penal, ao cumprimento de 2 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, o que é substituído por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período acima e por prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo. Tendo em vista que o réu respondeu ao processo em liberdade e que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, permito que ele continue nessa situação até o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.R.I.C.

Barueri, 19 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA